

1500024-52.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades transportar e trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500024-52.2020.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-52.2020.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2002863/2020 - DEL.POL.ARARAS, 9333697 - DEL.POL.ARARAS, 91/20/805 -

DEL.POL.ARARAS, 2002863 - DEL.POL.ARARAS, 91/20/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Nilson Bispo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face JOSÉ NILSON BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos, visando apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 14h10min, na Rua Galdino Fioravante Maestrello, defronte ao nº 65, Bairro Vila São Jorge, nesta cidade de Araras, JOSÉ NILSON BISPO DOS SANTOS, vulgo "Lorinho", qualificado a fls. 6, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de tráfico, transportava e trazia consigo, em peso líquido, 1,7g (um grama e sete decigramas) de cocaína, em oito porções e 107,3g (cento e sete gramas e três decigramas) de droga conhecida como maconha, em vinte e nove porções.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls.153) e apresentou preliminar (fls.159).

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2019 (fls. 161/162) e a ré citada (fls. 190).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos (fls.211/214 e 218/226).

O Ministério Público, pugnou pela procedência do pedido condenatório nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requer a absolvição, por falta de provas e, em caso de condenação, fixação de regime aberto.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminar de Defesa – Nulidade processual - Violação ao sistema cross examination.

Refuto preliminar de defesa, eis não ter havido qualquer violação à norma processual.

Com efeito, verifica-se que apenas houve de partida um convite aos ouvidos a fazerem uma breve exposição sobre os fatos que se recordavam, de forma plenamente livre, o que não representa violação do sistema acusatório, ou mesmo o comprometimento do atributo da imparcialidade. A propósito, a ementa:

"Apelação. Roubo majorado pelo emprego de faca. Recurso da Defesa. Preliminares: Nulidade da instrução por inobservância do procedimento desenhado pelo art. 212 do Código de Processo Penal. Inquirição inaugurada pelo juiz. Comprometimento da imparcialidade. Nulidade na tomada de declarações da vítima. Retirada do réu do ambiente virtual no qual era realizada a audiência. Indeferimento do pedido da defesa para inabilitação da imagem do acusado. Descumprimento do art. 217 do Código de Processo Penal. Alegação de violação da garantia da ampla defesa. 1. O marco regulatório do procedimento de produção da prova oral foi sensivelmente alterado por força da Lei 11.690/2008 que, ao superar o denominado "sistema presidencialista" de inquirição, estruturado na centralidade da atuação judicial, outorgou às partes protagonismo na exploração da prova testemunhal. Pelo regime antigo, que deita raízes na redação original da lei processual, a inquirição era desenvolvida pelo juiz com atuação complementar das partes que, para tanto, formulavam as perguntas por intermédio da autoridade judiciária. Pelo novo modelo (art. 212 do Código de Processo Penal), cabe às partes a primazia na exploração da prova oral. Não só inauguram a inquirição, como também o fazem de forma direta e, portanto, sem a intermediação do juiz. A este compete o papel fiscalizatório. Cabe-lhe indeferir as perguntas indutoras de respostas, assim como aquelas outras que se mostrarem impertinentes ou mesmo repetidas. Ao juiz é ainda permitida a complementação da produção probatória voltada para o esclarecimento de pontos duvidosos que emergiram no contexto da inquirição. 2. No enfrentamento das situações de afronta ao novo modelo de produção da prova oral, a jurisprudência vem identificando a violação do princípio acusatório, reconhecendo, dessa forma, o comprometimento do atributo da imparcialidade do julgador. Problemática que exige apreciação mais acurada sobre o sentido e o alcance do procedimento desenhado pelo art. 212 do Código de Processo Penal, identificando-se os reais interesses tutelados pela referida norma. 3. A tradicional dicotomia acusatório/inquisitório funda-se na leitura das manifestações do processo penal calcadas pela divisão ou pela concentração dos poderes de acusar e julgar. Assim, no processo inquisitório, a concentração daqueles poderes formata uma relação processual bilateral, ditada pelo confronto entre o juiz inquisidor e o acusado. Por sua vez, no processo penal de matriz acusatória a relação assume a geometria triangular em face da divisão de

poderes que lhe é própria. 4. A historiografia do processo penal revela a transposição dos processos de matriz inquisitória para aqueles de roupagem acusatória. Atualmente, mais do que a separação de poderes, a modelagem acusatória supõe uma reformatação dos poderes, funções e atividades do julgador ao longo da marcha processual reveladores dos resquícios inquisitórios. 5. A simples antecipação do juiz na produção da prova oral não expressa, de partida, uma violação do sistema acusatório, ou mesmo o comprometimento do atributo da imparcialidade. O problema não se encerra na iniciativa, mas sim na forma de sua realização. A exploração dos registros de memória da testemunha subtrai do acusador a atividade que lhe é reservada em decorrência do ônus probatório que lhe é imposto pelo princípio constitucional da presunção de inocência. É, portanto, na forma do proceder que resta o comprometimento da imparcialidade objetiva. Foi esta a percepção que ditou a redação do art. 3-A, incorporado pela Lei 13.964/2019 e cuja eficácia foi indevidamente suspensa. O dispositivo admite a iniciativa instrutória do juiz, vedando, contudo, a "substituição da atuação probatória do órgão de acusação". A questão é, portanto, de intensidade. 6. Hipótese em que o juiz, após tomar o compromisso de uma das testemunhas, que havia sido arrolada pela acusação, convidou-a a fazer uma breve exposição sobre os fatos que se recordava. Após o breve relato, deu-se oportunidade às partes para a inquirição direta da testemunha. Conduta legal e perspicaz da autoridade judiciária. De um lado, buscou estimular a testemunha à evocação espontânea de sua memória. Cuida-se de importante técnica que minimiza os riscos das falsas memórias. De outro, buscou assegurar a observância dos limites dados pelo thema probandum. Subtração da atuação probatória reservada ao órgão acusador não evidenciada. Violação do sistema acusatório não caracterizada. Não comprometimento da imparcialidade objetiva. 7. Nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal que incorpora dinâmica própria do processo adversarial, no qual reserva-se às partes o protagonismo na gestão do processo e, especialmente, na produção da prova. Interesse das partes na exploração dos meios de prova como forma de fixar, na mente do julgador, a sua visão sobre os fatos e os termos da imputação. 8. Hipótese em que a antecipação do juiz não representou uma inquirição antecipada ou mesmo subtração do movimento das partes, mas sim um estímulo à evocação voluntária dos traços da memória da testemunha. Não identificação de prejuízo que sequer foi especificado pela defesa em sede de recurso. Defensor que nada perguntou à testemunha dando-se por satisfeito com as respostas que haviam sido dadas à acusação. Nulidade não configurada. (...) ". (TJSP; Apelação Criminal 1500315-67.2020.8.26.0546; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Resta nítido que as partes não foram subtraídas no mister de formulação de perguntas aos ouvidos, respectivamente, não havendo qualquer intervenção abusiva do julgador e comprometimento da imparcialidade, do sistema acusatório e ofensa ao devido processo legal.

Assim sendo, refuto a tese defensiva de violação ao preceito insculpido no artigo 212 e parágrafo único do CPP.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 72/73), laudo químico-toxicológico (fls. 79/81), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado, negando autoria, disse que estava passando no local quando foi abordado pelos policiais militares. Disse que nunca foi preso anteriormente, que ajuda sua tia em um bar e faz alguns bicos. Indagado pelo membro

do MP, o acusado respondeu que só estava passando pelo local (fls. 207).

O policial militar Eric Moreli informou que estava em patrulhamento na região do local dos fatos quando recebeu informações de um popular que um indivíduo vulgo Loirinho estava comercializando drogas ilícitas. Disse que se dirigiram ao local dos fatos e avistaram o acusado, que ao ver a viatura acelerou os passos. Disse que o acusado foi abordado e, que em revista pessoal, encontraram vinte e nove porções de maconha e oito eppendorfs com cocaína, bem como a quantia de R\$30,50, em dinheiro trocado e um aparelho de telefonia móvel, no interior da pochete do acusado. Afirmaram que o acusado confessou a venda de drogas, apesar da negativa na delegacia. Indagado pelo MP, respondeu que o local que abordaram o réu era ponto conhecido por venda de drogas e que não conhecia anteriormente o acusado (fls.192).

No mesmo sentido, disse o policial militar Willians Miiller Cavalcante (fls.193).

Essas são as provas dos autos.

A versão do acusado está isolada nos autos e não prospera.

De fato, os policiais foram firmes e coesos ao narrarem a ocorrência, visto que estavam em patrulhamento e foram informados por um cidadão não identificado que indivíduo estava comercializando drogas ilícitas.

Se dirigiram ao local dos fatos e avistaram o acusado, que ao ver a viatura acelerou os passos. Os policiais abordaram e revistaram o acusado, encontrando com ele vinte e nove porções de maconha e oito eppendorfs com cocaína, além de quantia em dinheiro trocado, que estavam no interior da pochete do acusado, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas.

Lembre-se que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade. Ademais, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto”. (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

De fato, como servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Mirelles (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que “a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 100)

Na mesma linha, Edilson Mougnot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito”. (BONFIM, Edilson Mougnot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos

policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada. Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas"(RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado sem juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF, HC 73.518/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Celso de Mello, DJ 18/10/1996).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão. Isto porque, conforme previsto no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades transportar e trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico. Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc, não exigem especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap.697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de

Drogas Descabimento Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavra dos policiais militares Credibilidade Precedentes Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão Ausência de visualização de atos de mercancia Irrelevância Tipo misto ou de conteúdo variado Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017)

O conjunto probatório é harmônico e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista a quantidade, a natureza, diversidade e a forma como

estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha, em porções individuais). Aliado a isso, a quantia em dinheiro encontrada, o local da abordagem conhecido como ponto de venda de drogas, demonstram cabalmente que o réu praticava tráfico de drogas.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena

Primeira fase: Não havendo circunstâncias aptas a modificar a pena base, fixo esta em seu mínimo legal.

Segunda fase: Nada a considerar.

Terceira fase: Ausentes quaisquer causas de aumento.

Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. E isso porque, além de se tratar de um direito subjetivo, verifico que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e que não foram produzidas quaisquer provas indicativas de ser ela integrante de organização criminosa ou dedicado à atividades desse gênero.

No presente caso, a quantidade e diversidade encontradas não tem o condão de afastar a causa de diminuição. Se não se trata de quantidade significativa para afastar o benefício legal. Não há qualquer prova de que a ré integre organização criminosa, muito menos de que se dedique à atividade criminosa.

Conforme já restou decidido em casos semelhantes:

"Tráfico de entorpecentes (24,9g de cocaína, 9g de crack e 26,3g de maconha). 1. Negativa do réu isolada do conjunto probatório nos autos. Autoria e materialidade demonstrados. 2. Aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11343/06, na fração de 2/3 (dois provido." (TJSP; Apelação Criminal 0006805-48.2016.8.26.0635; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

"Apelação Criminal – Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 – Apreensão de 31 pedras de "crack", pesando aproximadamente 11,20g (onze gramas e vinte decigramas), 19 papalotes de "maconha", pesando aproximadamente 23,80g (vinte e três gramas e oitenta decigramas), e 27 cigarros de "maconha", pesando aproximadamente 27,50g (vinte e sete gramas e cinquenta decigramas) – Absolvição – Inadmissibilidade – Aplicação do § 4º, do artigo 33, da lei de drogas – Necessidade – Pena reduzida – Regime fechado – Alterado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Cabível – Sentença retificada – Apelo provido parcialmente – Expedição de alvará de soltura clausulado". (TJSP; Apelação Criminal 0000243-34.2016.8.26.0599; Relator (a): Borges Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 12/07/2017) Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem

íntegra organizaão criminosa. O  nus da prova, no caso,   do Minist rio P blico no sentido de demonstrar a reincid ncia, os maus antecedentes e a participa o em atividades criminosas ou organiza o criminosa. N o importa que a prova seja dif cil para o Minist rio P blico. Mais dif cil seria para o r u que, por sua vez, tem o direito de n o ser condenado a n o ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, Jo o Daniel. Lei de Drogas Anotada. S o Paulo: Saraiva, 2  Ed., 2008, p. 106-107).

Sendo, destarte, positivos os par metros previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, opero a diminui o no seu grau m ximo (2/3).

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o aberto, com base no Habeas Corpus n  596.603 - SP (2020/0170612-1), emanado pelo e. Superior Tribunal de Justia, que estabelece a aplica o de regime aberto aos crimes de tr fico privilegiado.

Pena restritivas de direitos. Poss vel a substitui o da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do C digo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretens o punitiva estatal para JOS  NILSON BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela pr tica do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n  11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclus o, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no m nimo legal.

Pena alternativa. Substituo a pena de pris o por duas restritivas de direitos, a saber: 1. presta o de servios sociais, a serem especificados pelo ju zo das execu es; e, 2. presta o pecuni ria no valor de um s l rio m nimo, mediante dep sito judicial, com destina o oportuna nos moldes das normas da E. CGJ.

Dever  ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no  9  do art. 4  da Lei Estadual n. 11.608/03.

Providencie a Serventia as comunica es e anota es de praxe. Determino a incinera o das subst ncias entorpecentes e o perdimento da quantia em dinheiro apreendidos nos autos. Observo haver delibera o acerca de celular apreendido  s fls.97.

Arbitro os honor rios ao defensor dativo no m ximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certid o.

Com o tr nsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS O   MARGEM DIREITA